

1500317-14.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que "... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500317-14.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500317-14.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2042603/2022 - DEL.POL.COTIA, 23016834 - DEL.POL.COTIA, 746/22/403 - DEL.POL.COTIA, 2042603 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO HENRIQUE BIAGIONI CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

FERNANDO HENRIQUE BIAGIONI CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 65/66).

Oferecida a denúncia (fls. 67), esta foi recebida (fls. 76/77) e o réu devidamente citado.

Após a apresentação de defesa escrita (fls. 108/121), o recebimento da denúncia foi

ratificado (fls. 103).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestou-se o Ministério Público em alegações finais orais, ao passo que a defesa técnica apresentou memoriais escritos (fls. 160/187), no qual alegou a inexistência de prova apta a embasar a condenação do réu, bem como arguiu a ilegalidade da atuação da guarda municipal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A arguição de que a prova é ilícita não prospera.

Não há nenhuma ilegalidade a abordagem do réu ter sido realizada por guardas municipais (que exercem a função repressiva).

Com efeito, “não se está a reconhecer o policiamento ostensivo das guardas municipais, mas sim a atribuição de funções essenciais à proteção da população local, bem como de bens, serviços e instalações.

É possível que, durante o patrulhamento preventivo, destinado à salvaguarda dos sobreditos bens jurídicos, o agente municipal se depare com situação de flagrante delito ou, ainda, que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir”.

No particular, os guardas estavam em patrulhamento e avistaram o réu nas proximidades de uma quadra, onde ocorria um evento. Note-se que os guardas garantiam a segurança do local público, de sorte que a abordagem ocorreu de forma legítima;

Ademais, destaco que não se pode ser leviano e deixar de levar em conta que no Brasil o tráfico de drogas tem sido praticado à revelia. É fato notório.

E isso, por óbvio, não é desconhecido pelos Guardas Municipais.

E a conduta do réu acertadamente motivou os guardas a proceder com a abordagem, já que é de sabença de quase todos (ainda mais dos guardas municipais, que atuam na linha de frente à criminalidade), em especial daqueles que atuam na área criminal, que a conduta do requerido foi totalmente suspeita, já que não é comum que alguém empreenda fuga quando aviste policiais ou guardas.

Dessa forma, sabedores de tais circunstâncias, agiram legitimamente os guardas civis.

Deveras, na situação em tela, não estão desautorizados de agir. Ao contrário, era mesmo a conduta que se exige de agentes estatais que, em última análise, integram o aparato de Segurança Pública.

Note-se que os agentes não passaram a realizar revista pessoal de forma aleatória, no autuado ou em qualquer outro transeunte. Apenas abordaram aquele que esboçou atitude evidentemente suspeita – que inclusive foi confirmada.

Ademais, como se sabe, o tráfico de drogas intranquiliza a população de bem e tem crescido exponencialmente, inclusive em razão do afrouxamento das instituições.

Essa difusão do narcotráfico, contudo, deve ser coibida também pela Guarda Municipal e pelo Estado-Juiz.

Ademais, há de ser valorizada a atividade perigosa e legítima desempenhada pela Guarda Municipal, sob pena se deixar a sociedade à mercê de malfeitores.

A Guarda Municipal local, extremamente devotada, é indispensável à repressão da criminalidade, inclusive à traficância, máxime quando esta acontece nas cercanias dos bens públicos municipais.

Ainda sobre a atividade dos guardas, anoto que o artigo 3º, inciso III, do Estatuto das Guardas Municipais (Lei 13.022/14), prevê expressamente, como princípio mínimo da atuação das guardas municipais, o patrulhamento preventivo.

Referido Estatuto ainda conferiu poder de polícia à classe, conforme incisos IV e XIV, do artigo 5º, que prescrevem que são competências específicas das guardas municipais "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social" e "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário".

E, corroborando, a Lei Complementar 63/2006, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras da Guarda Civil do Município de Cotia, prevê no artigo 18:

Art. 18 - Ao Guarda Civil Classe I e II compete:

I - executar o policiamento ostensivo, preventivo, uniformizado e armado;

Assim, procedendo à interpretação sistemática da lei de regência, novamente assento que se verifica que os agentes agiram no exercício do dever legal.

E, além de ser legítima a nobre atuação da Guarda Municipal, não se pode olvidar que a prisão do acusado se deu por conta de crime permanente.

De fato, o "tráfico de drogas é crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo", de modo que, a teor do quanto disposto no artigo 301, do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

De acordo com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a guarda municipal é legitimada, consoante o princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do CPP (RHC n. 7.916/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 6ª T, DJ 9/11/1998).

[...] IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017).

Na mesma esteira, é o entendimento do E. TJSP:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando, preliminarmente, reconhecimento

da ilegalidade da apreensão feita pelos Guardas Municipais. No mérito pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ou a fixação da pena-base no mínimo legal. Ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais. Inocorrência - Crime de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, e por qualquer pessoa. Neste caso, o estado de flagrância se mostrou aparente, de modo que lícita foi a atuação dos Guardas Municipais, os quais, inclusive, devem zelar pela segurança social. Ademais, qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301, do CPP) Mérito - Autoria e materialidade comprovadas - Réu que negou a prática delitiva - negativa que não prospera - [...] Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1500597-36.2019.8.26.0548; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Alegação de nulidade em virtude da abordagem realizada por guardas municipais - Inocorrência - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão em flagrante por qualquer pessoa e, evidentemente, a apreensão de coisas, objeto do crime - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava a droga apreendida para fins de tráfico - Depoimentos dos guardas municipais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime -- PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501175-83.2019.8.26.0617; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Portanto, legítima a abordagem levada a efeito pela guarda e, como corolário, não há nenhuma prova ilícita nos autos.

Não há outra preliminar a ser apreciada.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou o delito lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo químico toxicológico (fls. 100/102), que atesta pelo resultado positivo para cocaína e maconha, pelo relatório final (fls. 58/59), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Guardas Municipais Eli Pereira Aro e Joelson Pereira da Cruz, quando inquiridos em juízo, disseram que faziam patrulhamento nas imediações de uma quadra municipal, pois ocorria um evento no local, quando avistaram o réu, o qual empreendeu fuga ao avistar a guarnição. Durante a evasão o réu caiu ao solo e derrubou uma sacola que levava consigo. Em seguida, o acusado foi abordado.

Na sacola que era levada pelo réu os guardas encontraram as drogas apreendidas - 81 porções de maconha, 217 de cocaína e 231 de crack.

E a fala dos guardas, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os guardas não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. O raciocínio é análogo ao desenvolvido para depoimentos de policiais, já que ambos são servidores que atuam na área da segurança pública.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

As testemunhas arroladas pela defesa, Rafaela Carolina da Cruz e Patrícia de Oliveira, quando inquiridas em juízo, explanaram, de importante, que o acusado estava dentro do alambrado existente no local dos fatos, entendendo que tal fato impedia que ele fugisse ou portasse drogas.

O réu, quando interrogado, disse que no dia dos fatos estava dentro da quadra assistindo jogo e os guardas chegaram no recinto e o retiraram do local à força. Em seguida, os agentes começaram a procurar por algo em um mato e, após vasculharem, pegaram as drogas apreendidas, as quais não lhe pertencem.

Asseverou que estava do lado de dentro da quadra e que foi a única pessoa que os guardas mantiveram abordado.

Disse que desconhece os agentes e que eles praticaram tal fato em razão dos seus antecedentes.

Pois bem.

A imputação Ministerial é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que o acusado, de fato, estava a praticar a traficância.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte do réu, na medida em que levava consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes eram levados pelo réu, que os detinha especialmente para o fim de cometer a traficância, conforme asseverado pelas testemunhas hoje inquiridas, o que fica reforçado ao se analisar o conjunto das provas.

Destaca-se que, assim como ocorre com os policiais, os depoimentos dos guardas devem ser cridos até prova em contrário, pois "Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

A propósito, o fato de o réu levar consigo os entorpecentes é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que "... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante ..." (Apelação Criminal nº 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques da Silva).

A versão apresentada pelo acusado não deve ser acolhida, pois não há qualquer motivo apontado nos autos de que os agentes da lei esteja, gratuitamente, imputando ao réu a prática do tráfico de drogas. Da mesma forma, a depoimento prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa também devem ser desacolhidos, pois destoam das demais provas produzidas nos autos.

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou os isentem de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno FERNANDO HENRIQUE BIAGIONI CORREA, qualificado nos autos, como incurso artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase da dosagem, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto), pois há de se anotar que a conduta do requerido é mais reprovável do que a normal à espécie.

Com efeito, a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas com o réu seriam vendidas em porções fracionadas, de sorte que atingiriam muitas pessoas.

Assim, sua culpabilidade, diante disso, é mais acentuada.

Com efeito, tal entendimento foi confirmado no r. acórdão proferido nos autos de nº 0001381-11.2015.8.26.0360, com relação à sentença de lavra deste julgador:

“Em detida análise dos autos, de rigor o reconhecimento da pena-base acima do mínimo legal.

Ressalte-se que embora este Relator perfilhasse do entendimento que a quantidade da droga apreendida serviria para caracterizar o delito do tráfico de drogas, mas não era suficiente à exacerbação da pena-base, após minuciosa análise sobre o tema, filio-me ao entendimento de que a quantidade e natureza da droga, neste caso, recomendam a fixação acima do mínimo, o que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas.

O artigo 42, da Lei 11.343/06 prevê, de forma expressa, que na fixação das penas o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal: 'a quantidade da substância ou do produto', de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser considerado para agravar a pena.

Sobre o tema a seguinte jurisprudência:

'A natureza e a quantidade da droga são fatores que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.' (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, GJe 14/11/2011).

Porquanto, a quantidade de droga apreendida, frisa-se, justifica a exasperação da pena-base, assim como também entendeu o d. Magistrado a quo.” (TJSP - APELAÇÃO nº 0001381-11.2015.8.26.0360, 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Rel. Paulo Rossi, julgado em 19/10/2016).

Na segunda fase não há nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.

E, na terceira fase, não há nada a ser considerado.

Ainda, o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque o réu levava consigo expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância que indica que está efetivamente inserido em atividade organizada.

Deveras, “porque diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo”.

Isso demonstra que o acusado tem se dedicado a atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Portanto, o réu não faz jus à benesse referida, pois não se trata de debutante na prática de crimes.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obriguem o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há indicativos suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.



Assim, chego, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada, da quantidade de drogas e dos veementes indicativos de que o acusado está incisivamente inserido na traficância.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de

outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Ademais, impossível, igualmente, a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento dos objetos e do numerário apreendidos, se o caso.

Oportunamente, diligencie a serventia para comunicação ao Funad a respeito dos bens declarados perdidos nos autos, nos termos do artigo 63 e seguintes da citada Lei.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme já manifestado na decisão que determinou a prisão preventiva do réu, cujas razões tomo por empréstimo, uma vez não se verifica alteração do quadro probatório que motivou a segregação preventiva e porque ainda estão presentes circunstâncias de fato e de direito necessárias para manutenção da prisão.

Ademais, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019).

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Cotia, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA